

1500081-55.2022.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... inclusive em juízo, admitiu o tráfico interestadual. Observo que dificuldades financeiras não autorizavam a ré a lançar-se ao tráfico e, por conseguinte, não configuram excludente de ilicitude capaz de afastar o delito em comento. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Centro, Jaú - SP - cep 17210-100

https://tjsp-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/caiot_tjsp_jus_br/EaHa-1ZhXV50sFQA0SOMxXMBMeLAWIn1qJq8zJLczv8fqQ?e=JGpJe9

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500081-55.2022.8.26.0598 - Controle 2022/000196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040852/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22980812 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 806/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2040852 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIENIFHE LUCIA SILVA FERREIRA

Em 07 de julho de 2022, no horário designado, foi realizada audiência virtual, conforme disciplina estabelecida pela E. Corregedoria Geral da Justiça, sendo assegurado, antes do início da solenidade, o direito de entrevista reservada entre acusada e Defensor. Presente a MM Juíza de Direito, Dra. Ana Virgínia Mendes Veloso Cardoso, comigo, Escrevente, teve início a audiência para hoje designada no processo em questão, a qual foi realizada por meio de gravação na plataforma Microsoft Teams e anexada ao termo de audiência, conforme comunicado 1350/2020. Apregoadas as partes, constatou-se ter comparecido o Dr. Wellington Roger Neves, DD. Promotor de Justiça; o Dr. Rayclinge Luiz Viana Rocha OAB 11245/AM, Advogado, ora defendendo a acusada DIENIFHE LUCIA SILVA FERREIRA; a acusada referida; e as testemunhas Kleber Arao Silveiro De Souza Costa e Wallace Gamas Santos, que prestaram seus depoimentos. Após, procedeu-se ao interrogatório da acusada. Encerrada a instrução, em alegações finais, as Partes debateram oralmente, conforme gravação que segue. Em seguida, seguiu-se deliberação da MM. Juíza: "VISTOS. DIENIFHE LUCIA SILVA FERREIRA foi denunciada pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, "caput", combinado com o 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. A acusada foi notificada e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022. (p. 170) e a ré foi citada (p. 187). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado a ré. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação da ré. O Defensor requereu a aplicação das benesses legais. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação é procedente. A materialidade restou

demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico-toxicológico. A autoria é certa. Em juízo, a ré admitiu o delito e disse que era a primeira vez que efetuava o transporte de drogas. Aduziu, ainda, que levaria as drogas da cidade de Ponta Porã/MS até Vitória/ES. A confissão da ré foi corroborada pelas provas produzidas. Os policiais militares Kleber e Wallace confirmaram a apreensão de drogas na posse da ré durante fiscalização rotineira no ônibus em que ela viajava. Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado à ré, que foi surpreendida transportando significativa quantidade de entorpecente. De resto, a acusada, em todas as oportunidades em que ouvida, inclusive em juízo, admitiu o tráfico interestadual. Observo que dificuldades financeiras não autorizavam a ré a lançar-se ao tráfico e, por conseguinte, não configuram excludente de ilicitude capaz de afastar o delito em comento. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. 1. Rejeitada a alegação do estado de necessidade exculpante, seja como causa excludente da ilicitude, seja como causa de diminuição de pena (art. 24, §2º, do CP). As alegadas dificuldades financeiras do réu que seriam superadas pelo transporte da droga não justificam, de modo algum, o sacrifício de qualquer valor social, especialmente a saúde e a segurança públicas, bem como a paz social, considerando-se o alto poder viciante da droga traficada. 2. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. 3. Pena-base mantida, ante a vedação à reformatio in pejus no recurso exclusivo da defesa. 4. Mantida a aplicação da atenuante genérica da confissão. Redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto). Incidência da Súmula nº 231 do STJ. 4. Correta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, relativa à transnacionalidade do delito, haja vista que ficou bem delineado pela instrução probatória o fato de que a droga era proveniente do exterior. 6. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. Tudo indica que o envolvimento do réu com o narcotráfico tenha sido pontual, fazendo jus à minorante no patamar de 1/6 (um sexto), pois a conduta praticada pelo acusado foi inequivocadamente relevante, tendo ele se disposto a levar consigo a droga oculta em sua bagagem, em fundos falsos. 7. Fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. 8. Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão do quantum da pena aplicada. 9. Apelação da defesa parcialmente provida. (ACr 0012342-72.2015.4.03.6119 SP, Rel. Des. Fed. Nino Toldo, j. 31/01/2017). APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES DIFUSÃO EM PRESÍDIO ESTADO DE NECESSIDADE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA INEXISTÊNCIA DOSIMETRIA. I. Incabível o reconhecimento de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Não é justificável que, diante de dificuldades financeiras, não haveria outro proceder senão o de traficar droga para o interior de presídio em troca de recompensa pecuniária. II. A circunstância de o delito ter sido praticado no interior de estabelecimento prisional pode aumentar a pena-base se não foi utilizada para majorar a reprimenda na terceira etapa. III. Parcial provimento ao apelo para reduzir as penas. (Apelação Criminal 0013286-51.2015.8.07.0001 TJDF Rel. Sandra De Santis Mendes De Farias Melo, j. 30/06/2016). Comprovada, portanto, a infração penal indicada na denúncia, a condenação é medida que se impõe. Passo, pois, a dosar a pena. Na primeira fase, atentando ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a quantidade de entorpecente apreendida, apesar do seu menor potencial lesivo, se comparado a outras drogas. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de

calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"). Por conseguinte, mantenho a pena no patamar anterior. Na terceira fase, presente a causa de aumento descrita no inciso V do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Por fim, a despeito das alegações ministeriais, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que a acusada dedicava-se, há tempo considerável, a tal atividade criminosa ou integrasse organização criminosa. Todavia, cumpre observar que referido preceito legal fixa os requisitos necessários à sua aplicação, mas não estabelece parâmetros para escolha do quantum de diminuição a ser extraído entre as frações de 1/6 e 2/3. A esse respeito, oportuna a citação do Exmo. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Luiz Fux, esposada em seu voto no Habeas Corpus nº 111.097-MG: "Destarte, se se entender pela ocorrência de bis in idem em decorrência da consideração das circunstâncias atinentes à quantidade e à qualidade da droga na majoração da pena-base e na dosagem da minorante do § 4º da Lei de Drogas, o magistrado ficará sempre adstrito à aplicação da minorante na fração máxima, tornando letra morta o preceito legal que determina seja ela aplicada na forma escalonada, por isso, a conclusão há de ser pela ausência de sobreposição, notadamente porque a pena-base e a minorante têm finalidades distintas: a primeira encontra justificativa na sanção necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime, e a segunda visa a contemplar, com o abrandamento da punição, não necessariamente com a fração máxima de 2/3, o agente primário e de bons antecedentes que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INSTRUMENTO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. QUANTUM DE REDUÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGAS. MENOR FRAÇÃO. 1. O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas as circunstâncias previstas no art. 59 do e Supremo Tribunal Federal especialmente o disposto no art. 42 da Lei Antitóxicos. 2. Juízo de proporcionalidade que admite a aplicação do redutor no percentual mínimo de 1/6, de acordo com o previsto nos arts. 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do CP, dada a quantidade e a espécie de entorpecente encontrado em poder do acusado. 3. Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO." (STJ, AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.403.921-MG - 2011/0085663-6 - 6ª T - rel. Ministro Vasco Della Giustina, 23.08.2011, v.u.). Destarte, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendida, diminuo a pena do crime de ½, tornando-a definitivamente

em 3 anos, 4 meses 25 dias de reclusão e 340 dias-multa. Também por tal razão, fixo, apesar da primariedade da ré, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e pelos motivos esposados na primeira fase e circunstâncias do delito, que envolve transporte interestadual, de modo que a concessão dos benefícios mencionados, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, CP. O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, tendo em vista que não há comprovação de que a ré possa arcar com esta em valor superior ao mínimo. Por fim, consigno que, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão

provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer à lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico: "O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena. A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória. (...) A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão". Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena. A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença. Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais. E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia. Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min). Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade. E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia. Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar

para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir. Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR a ré DIENIFHE LUCIA SILVA FERREIRA, qualificada nos autos, à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 340 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Defiro o apelo em liberdade. Custas na forma da lei. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos." NADA MAIS. A sentença foi exibida ao Ministério Público e ao Defensor para ciência, que informaram que não desejam recorrer. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziere), Escrevente, digitei.

TERMO DE INTERROGATÓRIO

Antes da realização do interrogatório, foi assegurado o direito de entrevista reservada do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a) (CPP, art. 185). Informado(a) pela MMA. Juíza do seu direito de permanecer em silêncio e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186), o que não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa (CPP, art. 186, par. único), às perguntas sobre sua qualificação, respondeu o(a) acusado(a):

Nome: DIENIFHE LUCIA SILVA FERREIRA

RG: 2173784-3-SSP/AM, RJI: 224220428-38

Data De Nascimento: 26/09/1990

Filiação: pai JOSÉ RAIMUNDO FERREIRA, mãe ROSIVANE CRUZ DA SILVA

Residência: RUA UM, 20-A, telefone: 92-9-9524-8250, FRANCISCA MENDES 2, RUA UM, Manaus-AM

Ciente da acusação passou a ser interrogado(a), de acordo com o art. 187 do CPP. Às perguntas da MMa. Juíza de Direito, respondeu: "O interrogatório foi realizado da forma acima referida". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____(Caio C. T. Mazziero), Escrevente, digitei.